

1500907-21.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Comarca: São Bento do Sapucaí

Foro: Foro de São Bento do Sapucaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... do Estado de São Paulo:

"Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso buscando a absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, aplicação do redutor pelo tráfico "privilegiado" em patamar máximo e imposição de regime semiaberto. Processo penal. Prova. Tráfico ilícito de entorpecentes.

Testemunhos dando conta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bento do Sapucaí

Foro de São Bento do Sapucaí

Vara Única

Rua Capitão Procópio Marcondes Azeredo, 43, ., Centro - CEP 12490-000, Fone: (12)

2138-2408, São Bento do Sapucaí-SP - E-mail: saobento@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500907-21.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos -Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE VINICIUS BARBOSA RODRIGUES

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 05 de outubro de 2022, às 13:30h, na sala de audiências da Vara Única do Foro de São Bento do Sapucaí, Comarca de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA, por videoconferência, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou o MM. Juiz o comparecimento do representante do Ministério Público, Dr. Salomão Sussumu Tanaka dos Santos; do réu José Vinicius Barbosa Rodrigues acompanhado de seu Defensor, Dr. Antônio Carlos dos Santos OAB/SP 184596. Das testemunhas arroladas pelo Ministério Público: Luis Geraldo Ferreira Júnior, Billie Lucas Lucio de Campos e Thiago Zorzetto Goes, e das testemunhas arroladas pela defesa: Ana Tércia Gonçalves e João Paulo Gonçalves do Prado, todos por videoconferência. Iniciados os trabalhos, após entrevista reservada do réu com seu Defensor, pelo MM. Juiz foi determinado o registro dos principais acontecimentos nesta audiência, de

forma cronológica:

O MM. Juiz colheu o depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e das testemunhas arroladas pela defesa e, em seguida, procedeu ao interrogatório do réu.

As partes não requereram diligências complementares, nos termos do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: "Encerrada a instrução. Aos debates".

Pelo Ministério Público foi apresentada as alegações finais de forma oral conforme consta na mídia aos 41min44s, pleiteando pela condenação nos termos da denúncia.

Pela Defesa foi apresentada as alegações finais de forma oral aos 45min13s, conforme consta na mídia.

Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

"O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou (fls. 110/112) JOSE VINICIUS BARBOSA RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, porque, segundo consta, no dia 14 de julho de 2022, por volta das 6h10min, na Rua Vicente Chiaradia, 164, Centro, Santo Antônio do Pinhal, nesta comarca, trazia consigo, tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 79 papérolas de cocaína, 235 invólucros também de cocaína, 79 pedras de crack, 1 tijolo de maconha e 1 tijolo de crack, conforme fls. 10 e auto de constatação preliminar às fls. 21/22.

Segundo o Parquet, o acusado comandava o tráfico de drogas no município, vendendo drogas em seus estabelecimentos comerciais, bem como em sistema "delivery" em Campos do Jordão.

Consta, ainda, que, em busca domiciliar, Policiais Civis encontraram grande quantidade de drogas, bem como embalagens para acondicionamento de drogas, balança de pressão, anotação referentes à contabilidade do tráfico de drogas e R\$5.368,50 em cédulas e moedas.

Ante o exposto, requer seja ele condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A denúncia foi recebida em 08 de agosto de 2022 (fl. 41).

O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação (fls. 119/131).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fls. 194/195), foi designada audiência.

Em audiência de instrução realizada de forma virtual, por intermédio da Plataforma Teams, foram ouvidas cinco testemunhas e, ao final, interrogado o acusado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com a fixação de regime inicial fechado.

A Defesa Técnica, por sua vez, em alegações finais orais, requer a consideração da causa de diminuição do "tráfico privilegiado", com a fixação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Não havendo preliminares pendentes de apreciação, passo à análise do mérito.

O crime de tráfico de drogas está assim previsto:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500(quinzentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Da leitura do dispositivo apontado, depreende-se que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria e a responsabilidade criminal dos denunciados, momento em que se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto pelo artigo 52, I, da Lei 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: a) natureza e quantidade da substância apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente.

Os vários núcleos verbais constantes do artigo 33 da Lei de Drogas fazem dele um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Assim, mesmo que o agente pratique, em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único, haja vista o princípio da alternatividade.

Com efeito, o tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a substância entorpecente, já o bem jurídico tutelado é a saúde pública.

Dito isso, a confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da conjugação de dois elementos, quais sejam: a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade do delito corresponde à prova de sua existência, ou seja, são os elementos que demonstram a ocorrência do delito.

Na situação sob julgamento, a materialidade do delito resta comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13 e 47/48), auto de constatação preliminar (fls. 21/22) e laudo pericial definitivo (fls. 239/242), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Por sua vez, a autoria também restou devidamente comprovada nos autos, uma vez que o conjunto probatório demonstra que o acusado foi o autor do delito em análise, conforme elementos supracitados, bem como pelos depoimentos a seguir analisados. A testemunha Luís Geraldo Ferreira Júnior, Autoridade Policial, narrou que se recorda dos fatos; que é Delegado de Polícia em Santo Antônio do Pinhal e chegaram informações sobre o réu, que ele seria o traficante mais forte da localidade; que ele utilizaria a função de uber para fazer entrega delivery do entorpecente e teria pessoas trabalhando pra ele; que fizeram campanhas próximo ao local do trabalho dele; que o comércio dele também estaria sendo localizado para movimentar entorpecentes e o dinheiro produto do tráfico; que na residência do réu localizaram grande quantidade de entorpecentes e ele foi preso em flagrante no dia; que junto com a droga havia anotações, sacólés, anotações de movimentação financeira do tráfico, grande quantidade de dinheiro trocado; que foi apreendida grande quantidade de dinheiro trocado; que na busca domiciliar, ele confessou o tráfico; que ele não alegou nenhuma defesa nem apresentou resistência à prisão; que ele não afirmou a origem da droga, pelo que se recorda; que não conhecia o réu, apenas por essa investigação; que é delegado no município há algum tempo, mas por portaria; que é delegado por cerca de 02 ou 03 anos; que nunca prendeu usuários que teriam comprado droga do réu; que o réu colaborou e já apontou o entorpecente; que não houve resistência; que ele não é traficante iniciante, é que a cidade por ser pequena, as pessoas têm medo de colaborar; que possui 02 ou 03 policiais e ainda faz revezamento em Campos do Jordão; que há um morador de Campos e 02 de Taubaté; que não é comum, mas acontece a confissão espontânea de traficantes; que, pelo que tem conhecimento, esta deve ter sido a maior apreensão da história da cidade; que nunca houve apreensão de drogas nesse importe em seu tempo trabalhando no Município.

A testemunha Billie Lucas Lucio de Campos, policial civil, afirmou que receberam denúncia de pessoa que se dizia usuário e estava com medo do réu que narrava que o réu usava sua profissão de motorista de aplicativo para fazer vendas na cidade e em Campos do Jordão; que a denúncia dava muitos detalhes; que pediram mandado de busca e apreensão; que foi autorizado judicialmente; que foram em 03 lugares no dia, na casa do réu, na loja de sapato e outra no bar; que foi até a casa dele, na residência abordaram o réu com o seu enteado; que a esposa dele estava na residência também; que de pronto ele assumiu a autoria e mostrou os entorpecentes; que conduziram o réu, os entorpecentes e os petrechos pra delegacia; que os petrechos eram caderno, embalagens, e a droga em características de que estava sendo fracionada; que a droga aparentava ser fracionada ali mesmo na residência; que foi apreendido bastante dinheiro "picado"; que no veículo dele também havia uma quantidade razoável de dinheiro; que fizeram campana no bar e viram movimento muito suspeito; além disso, havia denúncias de delivery por meio do uber; que trabalha em

Campos do Jordão, mas faz operação conjunta na cidade desde agosto do ano passado; que inicialmente receberam uma denúncia, mas depois fizeram diligências na cidade, conversam com pessoas e possíveis usuários e todos apontavam pra ele; que muitos comerciantes apontavam do réu ser praticante do tráfico na cidade e usar a loja de fachada; que essas são diligências informais feitas antes de pedirem o mandado; que o Thiago estava presente em algumas diligências; que Tiago participou de várias campanhas; que não se recorda o total, mas fizeram várias campanhas no bar; que não abordou usuário no bar, pra não "queimar a campana"; que não faz abordagem no local da campana para não prejudicar a diligência; que não podem abordar o usuário saindo da biqueira, senão ele pode relatar, salvo se visualizarem situação de flagrante; que fazem isso através de diligência da Autoridade Policial; que a campana não precisa de comunicação judicial; que não se recorda agora do nome de algum efetivo comprador; que o réu colaborou na diligência e assumiu de pronto a prática do tráfico; que o Thiago Zorzetto também é de Campos do Jordão; que salvo engano, há 02 ou 03 na equipe de investigação em Santo Antônio; que também há um posto policial na cidade.

A testemunha Thiago Zorzetto Goes, policial civil, devidamente compromissado, relatou que a partir de uma denúncia anônima, com bastante detalhes, foi narrado que o acusado fazia delivery de drogas em Santo Antônio e Campos do Jordão; que fizeram diligências no bar dele, onde perceberam uma movimentação atípica, onde as pessoas entravam e saíam muito rápido, não ficavam bebendo; que isso meio que confirmou a mercancia de entorpecentes; que pediram mandado de busca; que sua equipe foi até a casa do réu; que no dia da incursão na casa, quando entraram, ele logo de imediato mostrou a droga, confessou e disse que ninguém mais da família estava envolvido; que dentre os objetos apreendidos, havia outros utensílios e dinheiro; que trabalha em Campos do Jordão desde agosto de 2021; que as informações são de que o investigado era o traficante mais forte em Santo Antônio, comandando o tráfico; que não tem conhecimento de outra apreensão de semelhante envergadura; que em Santo Antônio acha que tem 02 investigadores; a informação chegou pra "gente" e levaram conhecimento ao Delegado; que conhece os policiais de Santo Antônio e são bons policiais.

A testemunha Ana Tércia Gonçalves, ouvida em Juízo, narrou que conhece o réu há 30 anos; que o réu é trabalhador, pelo que sabe; que ele trabalhava na padaria e tinha uber; que ele é casado e tem 02 enteados; que um deles tem 16 e o outro 18 anos; que o réu é uma pessoa bem vista na localidade; que nunca ouviu comentário de que ele vendia drogas; que ouviu falarem que ele foi preso com drogas, mas antes não tinha escutado drogas; que não é possível que ele estivesse vendendo drogas ali; que nunca viu o réu ostentando riqueza, sempre foi trabalhador.

A testemunha João Paulo Gonçalves do Prado, devidamente compromissada, afirmou que mora em Santo Antônio há 25 anos; que trabalha na área da saúde, no serviço público; que é técnico de raio-x; que conhece o réu da cidade; que a cidade é pequena e acaba conhecendo todo mundo; que sempre viu o réu trabalhando com pintura e como padeiro; que ficou sabendo que o réu estava tocando um bar na cidade; que o réu possuía esse bar há 02 ou 03 meses; que não ouviu comentários de que ele estivesse envolvido com drogas e ficou surpreso; que acredita que saberia se ele traficasse há bastante tempo no local.

O réu, por sua vez, em solo policial, manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fls. 04 e 81). Em juízo, ao ser interrogado, confessou a autoria do delito, afirmando que traficada há 02 anos; que pagou em torno de 5.000 reais na droga; que depois da pandemia teve alguns trabalhos; que nunca teve outra ocorrência com drogas; que já encontrou drogas e levou na delegacia, há cerca de 07 ou 08 anos; que era uma sacola cheia de drogas; que possui um carro financiado em 05 anos; que se arrepende e pede desculpas.

Diante do contexto probatório, entendo que restou evidenciada a autoria em relação ao crime de tráfico de drogas.

A versão trazida pelos policiais foi firme, coesa, mantendo-se íntegra desde a fase policial, além de ser corroborada com os elementos materiais apresentados (auto de apreensão e laudo pericial), além da própria confissão do acusado de que estava praticando o tráfico no local.

Dessa forma, restou comprovado que, após denúncias anônimas e diligências prévias que apontavam o réu como responsável pelo tráfico de drogas no Município de Santo Antônio do Pinhal, a Autoridade Policial representou e foi deferida a busca e apreensão domiciliar.

Nessa diligência, cumprida em respeito a todos os trâmites legais e constitucionais, foi apreendida na posse direta do acusado grande quantidade de entorpecentes, de várias naturezas, além de outros instrumentos ligados ao tráfico. A versão trazida pelos policiais foi firme, coesa, mantendo-se íntegra desde a fase policial, além de ser corroborada com os elementos materiais apresentados (auto de apreensão e exame químico-toxicológico).

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Além disso, o réu é confesso.

O cotejo da prova oral deixa bastante evidenciada a existência do crime e a sua autoria, sendo relevante destacar que o acusado confessou a prática do delito, a qual já estava muito bem delineada pelos demais depoimentos colhidos e o conjunto probatório nos autos.

Por sua vez, em relação à destinação da droga para tráfico, esta é evidenciada pela enorme quantidade de entorpecentes apreendida (88,51g de cocaína dividida em 79 papérolas; 212,8g de cocaína, em mais 235 papérolas; 21,34g, divididas em 76 pedras de cocaína na forma de crack; 351,84g de THC, na forma de um "tijolo" de maconha; 120g,03g de cocaína na forma de crack, na forma de 01 tijolo com porções raspadas) juntamente com o conteúdo encontrado na perícia do aparelho celular (fls 77/79), bem como pelas circunstâncias do flagrante, com a apreensão de outros instrumentos relacionados à mercancia ilícita (balança de precisão, anotações do tráfico), além de grande semelhança de dinheiro em cédulas variadas, o que não deixa dúvidas de que a destinação das drogas era para realmente o comércio ilegal.

Portanto, o que se extrai dos elementos informativos colhidos em fase policial, quando confrontados com as provas amealhadas em fase instrutória, autorizam o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, nas modalidades "ter em depósito" e "trazer consigo".

Ressalto que se cuida, conforme delineado supra, de tipo misto alternativo, sendo prescindível qualquer ato de mercancia para a consumação do crime, bastando que o agente incida em quaisquer dos verbos nucleares. Anote-se:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.CONFIGURAÇÃO.

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRADIÇÃO DO ENTORPECENTE. O

aperfeiçoamento do crime de tráfico de entorpecentes não exige a efetiva tradição da droga, sendo igualmente inexigível a comprovação da mercancia. In casu, resta devidamente demonstrada a participação do acusado na trama delituosa, o que torna imperiosa a sua condenação. Recurso conhecido, mas desprovido."(STJ, REsp 623589 / SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. FIM DE AGIR. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do

exclusivo uso próprio (REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010). 2. Na hipótese, as instâncias originárias concluíram que o entorpecente apreendido - 1.473 g de haxixe - não se destinava exclusivamente ao consumo próprio do paciente. Inviável, nesta via, para afastar tal conclusão, o reexame do material fático-probatório produzido. 3. Ordem denegada."(HC 629.670/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 23/03/2021, grifei) (grifei). Portanto, o acusado cometeu o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, na forma descrita na denúncia.

Na mesma esteira, avalio não ser caso de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que, apesar da primariedade e da inexistência de indícios de participação em organização criminosa, a quantidade da droga apreendida e as demais circunstâncias evidenciam que ele se dedica às atividades criminosas.

Nesse contexto, vale ressaltar que não se olvida que o indivíduo que é surpreendido com grande quantidade de drogas pode fazer jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado, eis que tal conduta, por si só, não evidencia a integração em organização criminosa, quanto constatada a primariedade e bons antecedentes do acusado e ausentes outros elementos concretos que evidenciem o oposto.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE APENAS NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. APLICAÇÃO DO REDUTOR. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração 1/6 e afastar a equiparação da conduta à crime hediondo. 2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 3. O fundamento utilizado pela Corte local para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou mesmo que integrasse organização criminosa. 4. Embora a quantidade dos entorpecentes apreendidos seja parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, esta Corte vem decidindo que tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosas ou o fato de que ele integraria organização criminosa. 5. No mesmo sentido, são os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que firmam a possibilidade, em tese, de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. 6. Em verdade, o STF vem entendendo que a atuação no transporte de entorpecente, ainda que em grande quantidade, não patenteia, de modo automático, a adesão estável e permanente do apenado à estrutura de organização criminosa ou a sua dedicação à atividade delitiva. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 537763 MS 2019/0299416-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGENTE NA CONDIÇÃO DE TRANSPORTADORA - MULA. CAUSA DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REDUÇÃO MÁXIMA. REGIME MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Compreende esta Corte, alinhada a precedentes do

Supremo Tribunal Federal, que a condição de 'mula', por si só, não autoriza conclusão de integração a atividades ou organizações criminosas, necessário sendo a inclusão de elementos fáticos que tal conclusão autorizem - até porque pode se tratar de recrutamento único e eventual. Precedentes. 2. Tampouco o afastamento do grau máximo de redução da pena, pela privilegiadora do tráfico eventual, pode dar-se pela simples condição de mula, novamente se exigindo fatores concretos indicadores da de proporcional redução da pena. 3. Agravo regimental provido a fim de aplicar a fração máxima pelo tráfico privilegiado, fixar o regime aberto e conceder a substituição por restritivas de direitos. (STJ - AgRg no AREsp: 802675 SP 2015/0271700-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017).

No entanto, o conjunto probatório exposto nos autos é suficiente para concluir que o réu dedica-se às atividades criminosas, possuindo papel além do eventual e isolado transporte de drogas.

Isso porque, apesar da primariedade, restou suficientemente demonstrado nos autos que o acusado já era conhecido dos meios policiais pelas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, além de denúncias que lhe apontavam como pessoa que comandava o comércio ilícito neste Município. Diante disso, após diligências prévias e campanhas pela Polícia Civil, confirmou-se a existência de grande e suspeito movimento em imóvel vinculado ao réu, típico do tráfico de drogas - em confirmação às denúncias anônimas.

Após, deferida a busca e apreensão, foi encontrada no domicílio do acusado enorme quantidade de drogas, de diversas espécies (88,51g de cocaína dividida em 79 papérolas; 212,8g de cocaína, em mais 235 papérolas; 21,34g, divididas em 76 pedras de cocaína na forma de crack; 351,84g de THC, na forma de um "tijolo" de maconha; 120g,03g de cocaína na forma de crack, na forma de 01 tijolo com porções raspadas), além de outros instrumentos ligados ao tráfico, a qual configura a maior e mais relevante apreensão de drogas dos últimos anos nesta Comarca.

Dessa forma, o quadro é muito diferente daquele praticado por pequenos traficantes primários e sem antecedentes que são encontrados com pequenas porções de drogas, justificando o afastamento da causa de diminuição. Afinal, o réu foi apreendido com grande quantidade e variedade de drogas, a qual era de sua propriedade, diferenciando-se da situação das meras "mulas" ou "depositários" que recebem determinada quantia para guardar os entorpecentes em favor de terceiros.

Nesse sentido, os seguintes arestos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso buscando a absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, aplicação do redutor pelo tráfico "privilegiado" em patamar máximo e imposição de regime semiaberto. Processo penal. Prova. Tráfico ilícito de entorpecentes.

Testemunhos dando conta de que o apelante era o único morador da casa onde encontrados os entorpecentes. Ausência de indícios de que as testemunhas visem incriminá-lo falsamente. Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (99g de maconha em 2 porções, 11,4 g de cocaína em 40 porções, 12,7g de "crack" em 57 pedras, mais 28,9g em 4 porções médias), além de petrechos destinados embalado e razoável quantia em dinheiro. Destinação ao comércio devidamente atestada. Desclassificação impossível. Penal. Dosimetria. Tráfico de entorpecentes. Redutor que nem mesmo se mostrava cabível, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Circunstâncias que, ao menos, justificaram redução menor na pena. Aplicação no máximo de 2/3 não se mostra cabível. Penal. Tráfico de entorpecentes. Fixação de regime inicial fechado. Necessidade. Observância da Lei de Crimes Hediondos. Aplicação de penas alternativas e concessão de sursis a traficante. Impossibilidade. Ausência de inconstitucionalidade no artigo 44, caput, da Lei de Tóxicos. Recurso desprovido" (9ª Câmara Criminal Extraordinária, Ap. 0002687-73.2014.8.26.0352, Des. Rel. Souza Nery, j. 19.05.2017) - destaquei

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Ministério Público pretende a condenação, majoração da base, reconhecimento da agravante do inciso VI do artigo 40 da Lei de Drogas e não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado além do regime fechado para cumprimento da pena. MÉRITO. Condenação é medida que se impõe. Acusado negou a prática delitiva. Versão dos policiais e do

menor infrator contrariam a tese absolutória. Grande quantidade de drogas apreendidas, embaladas especificamente para o fim de traficância afastam a alegação de usuário. A versão dos milicianos manteve-se coerente durante todo o curso do processo e deve prevalecer. DOSIMETRIA. Pena base fixada no mínimo legal, 05 (cinco) anos e 500 dias-multa, ante expressa vedação da Súmula 444 do STJ. Sem alterações na segunda fase. Na terceira fase, pena agravada em 1/6 por força do artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/2006, alcançando e tornado fixa em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no piso. Impossível reconhecimento do tráfico privilegiado. Regime fechado. Recurso provido. - Sentença reformada." (8ª Câmara Criminal Extraordinária, Ap. 0005665-27.2012.8.26.0050, Des. Rel. Carlos Monnerat, j. 07.02.2017) - destaquei "Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de 4 kg de cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a redução da reprimenda, o reconhecimento da figura privilegiada e a atenuação do regime prisional. Materialidade e autoria comprovadas. Traficância configurada. Réu preso em flagrante com elevada quantidade de entorpecente e petrechos para refinaria. Majoração da pena base em metade fundamentada na quantidade e qualidade de entorpecentes deve prevalecer. Confissão parcial não utilizada como razão de decidir, não sendo obrigatória a sua aplicação. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos devido à quantidade de entorpecentes apreendidos, compatível com traficante de grande porte. Regime inicial fechado deve prevalecer, pela gravidade e hediondez do crime. Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos - vedação legal. Recurso não provido" (8ª Câmara de Direito Criminal, Ap. 0036553-10.2014.8.26.0114, Des. Rel. Carlos Monnerat, j. 18.02.2016) - destaquei Por conseguinte, comprovadas a materialidade e autoria do delito tráfico de drogas, com privilégio, conforme art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a deflagração da responsabilidade penal é medida que se impõe, com o que passo, agora, à fase da individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria, inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, tem-se que são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Nesse passo, destaca-se que a grande quantidade da droga para os padrões desta Comarca justifica a elevação da pena, tratando-se da maior apreensão de drogas em anos neste pacato Município. Nesse sentido, os registros fotográficos e laudo de fls. 239/242, que demonstra a apreensão de 79 papelotes de cocaína (88,51 gramas), mais 235 papelotes da mesma substância (212,80 gramas), 76 pedras de crack (21,34 gramas), 1 tijolo de maconha (351,84 gramas) e 1 tijolo de crack (120,03 gramas). A par disso, acerca da natureza e variedade das drogas, por constarem da Lista F do Anexo I (substâncias de uso proscrito, ou seja, proibidas sob quaisquer circunstâncias ou concentrações pela natureza intrinsecamente nociva que possuem), merecem valoração mais gravosa nesta fase a cocaína - e em maior grau o crack, seu derivado, por causar severa dependência em seus usuários e ter alto potencial lesivo

Por outro lado, em relação às circunstâncias judiciais previstas no Código Penal, a culpabilidade não ultrapassou a esfera de normalidade ao tipo penal; o réu é primário e os atos infracionais não podem ser utilizados como maus antecedentes (STJ - HC: 374624 SP2016/0269323-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ21/08/2017); não há elementos seguros para valorar a conduta social do réu; tampouco a personalidade do agente, uma vez que demanda análise científica que escapa ao conhecimento técnico do Juiz; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo; e não há comportamento da vítima relevante para valorar.

Diante da multiplicidade e gravidade das circunstâncias judiciais negativas, elevo a pena mínima em 1/3 (1/6 para cada circunstância), e fixo a pena base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Presente a atenuante da confissão, reduzo a pena base em 1/6, estabelecendo a pena provisória em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, o que resulta na pena definitiva em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa. Diante da quantidade de pena e da gravidade das circunstâncias judiciais (ressaltando-se que se trata de uma das maiores apreensões de drogas da história do Município, o regime inicial para início do cumprimento da pena conforme será o FECHADO, consoante art. 33, § do Código Penal. Deixo de aplicar a detração preconizada no artigo 387, §2º, do CPP e na súmula 716 do STF, para não invadir a seara de competência do juízo da execução, uma vez que o regime inicial não será modificado mesmo após o reconhecimento do instituto. Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a pena foi aplicada em patamar superior a quatro anos de reclusão, afastando os requisitos do art. 44, do Código Penal. Igualmente, tendo em vista que o quantum da pena aplicada ao caso concreto, incabível a incidência do art. 77, do Código Penal. Em relação ao valor unitário da multa, a teor do art. 49, § 1º, do Código Penal, entendo pela aplicação de 1/30 do salário mínimo, pois não há dados sobre a situação econômica do réu.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu JOSE VINICIUS BARBOSA RODRIGUES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

EXPEÇA-SE guia provisória, com urgência.

Transitada em julgado a presente sentença:

- a) Expeça-se a guia definitiva, encaminhando-se ao juízo das execuções criminais;
- b) Intime-se o acusado para pagamento dos dias-multa, no prazo de 10 dias;
- c) Oficie-se o Instituto de Identificação do Estado de São Paulo, bem como ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF;
- d) Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais na forma da lei.

Por fim, MANTENHO a prisão preventiva, uma vez que o réu respondeu à instrução processual custodiado e não há alterações de fato ou direito que mitiguem o periculum libertatis, o qual restou reforçado com a sentença condenatória. Assim, embasado no art. 312, do Código de Processo Penal, entendo estarem presentes os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Sentença publicada em audiência."

Indagados, o Ministério Público manifestou desinteresse em recorrer. O réu e seu Advogado manifestaram interesse em recorrer.

Assim, pelo MM. Juiz foi dito: "A sentença transita em julgado para o Ministério Público nesta data. Aguarde-se o decurso de prazo para apresentação das razões recursais, considerando-se o recurso de apelação interposto nesta data, saindo as partes intimadas"

Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema, conforme arquivo importado e vinculado a este Termo com a seguinte minutagem: Luis Geraldo Ferreira Júnior aos 01min05s, Billie Lucas Lúcio de Campos aos 09min22s, Thiago Zorzetto Goes aos 19min47s, Ana Tércia Gonçalves aos 25min50s, João Paulo Gonçalves do Prado aos 29min20s e José Vinicius Barbosa Rodrigues aos 33min50s.

Saem os presentes intimados. Nada mais. Lido e achado conforme segue digitalmente assinado pelo MM Juiz. Eu, Maria Laura da Silva França, digitei.